

1500064-81.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... prova certa de que se dedique unicamente ao tráfico e, também, por não ser reincidente, havendo notícias que o lugar fosse ponto de tráfico e certamente haja outros envolvidos consigo na estratificada função, afinal, há o plantio, colheita, extração da pasta, refino e mesmo a embalagem até chegar no ponto de tráfico, como o caso, então, certo de que integra, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 3125-4133, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 11 de fevereiro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____,
Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500064-81.2021.8.26.0621 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE SILVA MARTINS

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

JOSUÉ SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta de 15 horas e 30 minutos, na Rua Manoel de Castro Nogueira, bairro Jardim do Vale II, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com terceiros não identificados, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em 9,48 g (nove gramas e quarenta e oito

decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supra, Josué, juntamente com duas pessoas não identificadas, realizava o tráfico de entorpecentes na via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a aproximação de policiais militares, tentou empreender fuga.

Contudo, ao ser alcançado e abordado pelos milicianos, estes lograram encontrar em seu poder 08 (oito) tubos eppendorf, contendo cocaína, além do valor de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), proveniente da atividade espúria.

Os comparsas do investigado conseguiram se evadir da cena delituosa.

Na ocasião, Josué admitiu aos policiais militares que estava praticando tráfico de drogas na companhia de pessoas cuja identidade manteve em segredo.

Frente a tais evidências, Josué foi preso em flagrante.

Veio aos autos, Auto de Prisão em Flagrante às fls. 1/2, do Auto de Exibição e Apreensão às fls. 13/14 e Laudo Pericial Definitivo às fls. 93/95, o qual resultou positivo para cocaína.

A denúncia foi recebida às fls. 158/159.

O réu, devidamente citado às fls. 149, apresentou defesa prévia às fls. 155/157.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, às fls. 171/172, uma testemunha de defesa às fls. 174, sendo, ao final, o réu interrogado às fls. 173.

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a procedência da Ação, alegando que a existência do crime restou devidamente comprovada, bem como a sua autoria resultou indiscutível. Quanto à dosimetria da pena, requereu que a pena seja ela fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a reprovável conduta social do agente (fls. 184/189).

A Defesa do Réu, por sua vez, postulou pela absolvição do réu pela ausência de provas da prática do crime imputado ao acusado, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal (fls. 194/203).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico dito praticado pelo Réu, que agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com terceiros não identificados, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em 9,48 g (nove gramas e quarenta e oito decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ausentes preliminares, quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas como sendo realmente a droga em questão, cocaína, prévia e definitivamente, de acordo com o Laudo de Exame Toxicológico Provisório e Laudo Pericial Definitivo às fls. 93/95. A autoria, por sua vez, é igualmente certa e indubitosa a partir do que nos autos consta, senão vejamos:

P.P.S.S., policial militar, ouvido em juízo (fls. 172), declarou que, na data dos fatos, juntamente com sua equipe, realizava patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima, informando a ocorrência de tráfico de drogas nas imediações do bairro Jardim do Vale II. Ato contínuo, ao chegar no local, avistou três indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como Josué Silva Martins, os quais, ao perceberem a chegada dos policiais, empreenderam fuga. Todavia, com Josué, detido e submetido à revista pessoal, deu-se o encontro das drogas descritas na inicial acusatória, além da importância em espécie de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), proveniente da atividade espúria. Por sua vez, os comparsas do acusado conseguiram se evadir da cena delituosa, não sendo identificados. Por fim, a testemunha esclareceu que, informalmente, o acusado confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como a prática da traficância.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar F.S.S. (fls. 171), que participou da prisão em flagrante do acusado e corroborou a narrativa de seu colega

de farda.

O Réu, Josué, em seu interrogatório (fl. 173), negou a prática do crime de tráfico, alegando que, no momento da abordagem, estava realizando a compra de drogas para o consumo pessoal.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Desta forma, observo que o delito de tráfico está devidamente caracterizado e o Autor corretamente identificado, conforme veremos linhas a seguir.

Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que o réu mantinha em sua posse e em depósito, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em 9,48 g (nove gramas e quarenta e oito decigramas) de cocaína

O Réu Josué, em seu interrogatório, negou as acusações, alegando que, no momento da abordagem, estava realizando a compra de drogas para o consumo pessoal.

Porém, os policiais afirmaram que ele confessou informalmente no momento da prisão que a finalidade era a traficância e reservou-se de falar quem eram os comparsas que fugiram, então, no conhecido "segurar o B.O." e mantinha dinheiro consigo, sabendo-se que usuários enquanto dispõem de dinheiro não param de usar, aliás, até vendem tudo o que têm dentro de casa para adquirir entorpecentes ou trocam por drogas, fazendo a vida de familiares um verdadeiro inferno, de maneira que seria de todo improvável que ainda tivesse o numerário consigo, pois, enquanto dele dispõe estão usando. Também não é coerente que já estivesse com a droga e não tivesse passado o dinheiro se fora lá para adquirir, já que o traficante recebe e serve. Mas, de qualquer forma, repiso, assumiu aos policiais a traficância.

Os testemunhos dos policiais, lado outro, não podem perder relevo e valor apenas pela palavra do flagrado com drogas e dinheiro, até porque policiais sem nenhuma mancha em ficha e que não teriam motivos para verem um inocente condenado injustamente. Sequer conheciam o acusado, não tendo afirmado este algo em contrário.

Neste diapasão, observo que o delito de tráfico está devidamente comprovado pelo que nos Autos consta.

Desse modo, o argumento da defesa no sentido de improcedência da ação não merece prosperar, pois ficou muito evidente pelas provas produzidas a autoria e culpabilidade do Réu.

Então, quanto à tipicidade tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Exatamente o que aconteceu no caso, pois nenhuma dúvida há sobre a conduta ilícita do Réu, consoante documentos e testemunhos carreados ao bojo dos autos.

Assim, tenho que o delito encontra perfeitamente caracterizado e o Autor corretamente identificado.

Logo, a condenação se impõe e a pena a ser aplicada deve ser a prevista para o

crime de tráfico, ou seja, mais precisamente a do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Apenas para que não fique sem exame, o exame toxicológico pedido, não se apresenta viável neste momento, pois não Requerido antes, senão agora em alegações finais, não se tendo sequer um indício de eventual problema mental no acusado e o simples uso de drogas não o isenta de pena, até pelo contrário, se de fato use e trafique. Nesse sentido anoto que a dependência de tóxicos, a toxicomania é uma doença que pode tornar a pessoa inimputável, enquadrando-se no art. 26 do CP, como regra geral. Todavia, em face da especialidade, deveremos nos ater à Lei de Tóxicos, que trata da hipótese da dependência. Não se trata aqui de cometer o crime drogado, pois aí é o mesmo tratamento dispensado à embriaguez. Conforme o grau de dependência o agente será inimputável ou semi-imputável.

A lei prevê duas situações: a) em razão da dependência; ou b) sob o efeito de substância. Na primeira hipótese o agente comete o crime, porque é dependente, não precisa nem estar drogado; na segunda hipótese, está drogado, não precisando ser dependente. A novidade cinge-se à primeira situação e sua especialidade, pois a segunda enquadra-se na generalidade do art. 28.

Na dependência grave fica afetada a capacidade de querer, não conseguindo o toxicômano sobrepor sua vontade à dependência. Então, conforme a dependência, será causa de inimputabilidade, total ou parcial, em razão do critério biopsicológico. Em regra, os crimes mais comuns cometidos pelo dependente é o tráfico, o furto e o roubo.

Tudo isso para dizer que se houvesse indícios demonstrados, a busca não seria pela simples dependência, mas sim se essa dependência afetou a sanidade mental do acusado total ou parcialmente e, se o caso, inimputável ou semi-imputável. Mas como dito, nada se notou e nem trouxe o acusado sobre eventuais internações, medicações receitadas ou qualquer outro.

Por outras palavras, é de se dizer que não basta se verificar a dependência, devendo o estudo ser, se o caso, de insanidade propriamente, mesmo que decorrente do uso continuado de drogas (como a que ocorre do uso de bebida alcóolica, de doença degenerativa da mente - v.g., sífilis).

Assim, a questão levantada pela Defesa, só agora, pedindo um exame, é irrelevante, tendo em vista que as demais provas colhidas nos autos corroboram com o fato de que o Réu realmente traficava, como vimos, não sendo incapaz de entender o caráter ilícito disso e muito menos de se determinar de acordo com esse entendimento.

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu é tecnicamente primário (fls. 141/142 e 143/144), tem condenação, mas sem trânsito em julgado; à conduta social, sem elementos para traduzi-la, embora indícios de que esteja no mundo do crime já há mais tempo; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do Réu; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade desse tipo de delito; às consequências do crime, são de extrema gravidade, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás a coletividade é que é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública). Deixo, portanto, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e a multa pecuniária, em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n.

11.343/06).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação da pena provisória e, neste sentido, observo que ausentes, apesar de envolvimento criminais (fls. 141/142 e 143/144), portanto, permanecendo a pena inalterada.

III- PENA DEFINITIVA

Ausentes quaisquer circunstâncias especiais ou gerais capazes de ensejar o aumento ou diminuição das penas encontradas, torno-as definitivas no montante encontrado na fase inicial.

Não é possível beneficiá-lo nos termos do § 4º do art. 33 da lei de tóxicos, porque, tem envolvimento com o crime, pois, embora a sentença sem trânsito, já foi condenado pelo tráfico recentemente e neste episódio estava com outras pessoas, sendo muito provável seu envolvimento com quadrilhas especializadas.

Aliás, registro, lado outro, apesar de não haver prova certa de que se dedique unicamente ao tráfico e, também, por não ser reincidente, havendo notícias que o lugar fosse ponto de tráfico e certamente haja outros envolvidos consigo na estratificada função, afinal, há o plantio, colheita, extração da pasta, refino e mesmo a embalagem até chegar no ponto de tráfico, como o caso, então, certo de que integra, de alguma forma, uma verdadeira rede de tráfico. Como os que fugiram da abordagem.

DECIDO.

Posto isso, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na denúncia de fls. 116/119, para o fim de CONDENAR JOSUÉ SILVA MARTINS, já qualificado, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e a multa pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, então, o cumprimento da pena se dará dessa forma, obviamente ressalvada a competência do Juízo da Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais. Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento.

Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos¹, que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

A doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter.

Vale dizer, conforme tal doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a um determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, ou seja, seria, por exemplo, passível um condenado a pena inferior a 8 anos (nesse caso mesmo que superior, descontado o tempo da cautelar, se assim resultasse inferior a 8 anos, aliás, como foi o exemplo doutrinário, se caberia, a critério do magistrado, o regime mais brando, mas não neste que é regime inicial fechado independente da pena, como visto).

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório etc.).

Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo -

(examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave do Réu preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO Nº 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação nº 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori - Desembargador Relator"

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Originariamente não se apresentava possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, já que em crimes da espécie a lei especial vedava expressamente, mas foi suspenso pelo Senado esta parte após julgamento no STF. Ipsis litteris:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Porém, não se apresenta possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

O crime pelo qual restou condenado o Réu tem vedação expressa do benefício do sursis, independentemente do quantum da pena imposta, a qual na maioria das vezes também impede a obtenção do benefício (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal).

DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o Réu respondeu todo o processo preso, quando já condenado por outro, que acabou solto e cometeu este, agora que condenado, com mais razão deve continuar, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional.

Após o trânsito em julgado lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República).

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistido por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB.

P.R.I.

Guaratinguetá, 11 de fevereiro de 2022.